

第30問

甲は、自転車で路上を走行していたところ、妊婦であるAがわき道から甲の走行している路上へ出てきたことに気が付いた。甲は以前自分を罵倒したことのあるAに恨みを持っており、Aを痛めつけてやろうと自転車でAにぶつかった。

Aは、その場で転倒し、腹部を地面にぶつけたが、A自身には、これといった症状はなかった。

以上の事実を前提に、Aの転倒により、Aの体内にいた胎児が身体に障害を抱えて出産予定日に産まれてしまった場合と障害なく産まれたが出産予定日よりも1か月早く、未熟児として産まれてしまった場合における、甲の罪責について、論じなさい。

第1 Aの体内にいた胎児が身体に障害を抱えて産まれてしまった場合

1 いわゆる胎児性傷害の問題である（**論点** 胎児性傷害）。

総合 169 頁 論証 70 頁

この問題について、最決昭63.2.29【百選Ⅱ2】は、「現行刑法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと取り扱われていると解されるから、業務上過失致死罪の成否を論ずるに当たっては、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない。そして、胎児が出生し人となった後、右病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するから、病変の発生時において客体が人であることを要するとの立場を採ると否とにかかわらず、同罪が成立するものと解するのが相当である。」と述べ、胎児に対する業務上過失致死罪（211）が成立するとした。

これは、錯誤論における法定的符合説（抽象的法定符合説）を転用するものと解される（長島補足意見参照）から、本問のような故意犯の事案にもその射程は及ぶと考えることができる。

判例の立場に従えば、胎児に対する傷害罪が成立する。

2 なお、Aに対する暴行罪（208）又は傷害罪（204）も成立し、胎児に対する傷害罪とは観念的競合となる（54 I 前段）。

第2 胎児が障害なく産まれたが出産予定日より1か月早く、未熟児として産まれてしまった場合

1 この場合には、不同意堕胎罪（215 I）の成立が考えられるが、問題は故意が認められるかという点である。

2 いわゆる抽象的事実の錯誤の問題として、構成要件に実質的な重なり合いを認めた場合には不同意堕胎罪が成立し（なお、傷害罪については客観的構成要件該当性がないが、不能犯の問題の一種として、危険発生を認めた場合、傷害罪の未遂、すなわち暴行罪が成立することになる。もっとも、暴行罪よりも不同意堕胎罪の方が重いから、そちらに吸収されることになるだろう。）、重なり合いを否定した場合には、故意（38 I 本文）がなく、不同意堕胎罪は成立しない（**論点** 抽象的事実の錯誤

総合 39 頁 論証 8 頁

■ 司H27,予H23,H28,旧H11-1）。

成立するとしても、暴行罪に止まることになる。

答案構成

第1 Aの体内にいた胎児が身体に障害を抱えて産まれてしまった場合

1 不同意堕胎罪（215 I）不成立

↓

2 傷害罪（204）の成否

↓

胎児は産まれるまでは、母体の一部であると考えべき

↓

胎児への攻撃は、母体という人に対する傷害であり、産まれた子という人に傷害結果が発生するのであるから、一種の具体的事実の錯誤の問題である

↓

法定的符合説

↓

胎児（生まれた子）に対する傷害罪成立

↓

3 Aに対しては暴行罪（208）成立

↓

4 両罪は観念的競合（54 I 前段）になる

第2 障害なく産まれたが出産予定日よりも1か月早く、未熟児として産まれてしまった場合

1 不同意堕胎罪の構成要件に該当する

↓

2 不同意堕胎罪の構成要件を傷害罪の故意で実現したことになるところ、重い傷害罪で処断することはできない（38 II）

↓

抽象的事実の錯誤

↓

法定的符合説

↓

不同意堕胎罪の限度で重なり合いが認められるから、その限度で故意が認められる

↓

3 不同意堕胎罪が成立する

第1 Aの体内にいた胎児が身体に障害を抱えて産まれてしまった場合

1 甲がAを痛めつけてやろうと自転車でAにぶつかった行為について、
分娩時期は早まっていないから、不同意堕胎罪（215条1項）は成立
しない。

2 一方で、産まれてきた子の身体に障害が発生しているから、この点を
捉えて、「人の身体を傷害した」ものとして傷害罪（204条）が成立
しないか。

(1) 胎児は産まれるまでは人ではないから、直ちに傷害罪の成立を認め
ることはできない。

しかしながら、胎児は産まれるまでは、母体の一部であると考え
べきである。そうすると、胎児への攻撃は、母体という人に対する傷
害といえる。その上で、産まれた子という人に傷害結果が発生するの
であるから、一種の具体的事実の錯誤の問題である。

(2) 故意責任の本質は、犯罪事実の認識によって反対動機が形成できる
のに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。そして、
犯罪事実は刑法上構成要件として類型化されているから、認識した内
容と発生した事実がおよそ構成要件の範囲内で符合していれば犯罪事
実の認識があったと考えられ、故意（38条1項本文）が認められる
と考える。

そうだとすれば、Aと胎児（産まれた子）は「人」という範囲で一
致しているから、構成要件的な符合が認められる。

また、このように解する以上、故意の個数は問題とならない。

1

(3) よって、胎児に対する傷害罪の成立を認めることができる。

3 Aに対しては、痛めつけてやろうという傷害罪の故意をもって暴行を
加えたものの、A自身には、これといった症状はなかったから、「暴行
を加えた者が人を傷害するに至らなかった」ものとして、暴行罪（20
8条）が成立する。

4 胎児に対する傷害罪とAに対する暴行罪は、「一個の行為が二個以上
の罪名に触れ」る（54条1項前段）場合に当たるから、観念的競合と
なる。

第2 胎児が障害なく産まれたが出産予定日より1か月早く、未熟児と
して産まれてしまった場合

1 この場合、分娩時期が早まっているため、「女子の嘱託を受けない
で、又はその承諾を得ないで堕胎させた」ものとして、不同意堕胎罪
（215条1項）の客観的構成要件に該当する。

2(1) もっとも、甲は、Aを痛めつけてやろうと思っているから、不同意
堕胎罪の構成要件を傷害罪の故意で実現していることになる。

この場合、傷害罪については、客観的構成要件該当性がないから同
罪で甲を処断することはできない。

(2) では、軽い不同意堕胎罪で処断することはできないか、いわゆる抽
象的事実の錯誤の問題となる。

故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機が形成できるの
に、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。そして、犯
罪事実は刑法上構成要件として類型化されているから、構成要件該当

2

事実の認識がなければ反対動機の形成可能性がなく、原則として故意は阻却されるということになる。

ただし、構成要件に実質的な重なり合いが認められる場合には、その限度で反対動機を形成することができる。したがって、そのような場合には、その限度で故意責任を問うことができると考える。かかる実質的重なり合いの有無については、①両罪の行為態様、及び②被害法益の共通性をもって判断すべきである。

(3) 不同意堕胎罪と傷害罪は、女子の身体に対する不法な有形力の行使という点で行為態様に重なり合いがある。

また、不同意堕胎罪の保護法益には、女子(妊婦)の生命・身体が含まれるから、傷害罪の保護法益たる人の身体の安全と、女子の身体の安全の限度で重なり合いを有する。

したがって、不同意堕胎罪の限度で重なり合いが認められるから、その限度で故意が認められる。

3 以上より、甲には、不同意堕胎罪が成立する。

以上

3

4